

1512852-04.2021.8.26.0177

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: PATRICIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI  
Comarca: Embu-Guaçu  
Foro: Foro de Embu-Guaçu  
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Na hipótese, a redutora do tráfico privilegiado não foi afastada somente em razão da quantidade e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guaçu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512852-04.2021.8.26.0177 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512852-04.2021.8.26.0177

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192737/2021 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 19085670 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 1185/21/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2192737 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PIERRY FERREIRA MACEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRICIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI

VISTOS.

PIERRY FERREIRA MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 16 de julho de 2021, pela manhã, no endereço descrito com a inicial, o denunciado expôs à venda, ofereceu, tinha em depósito, transportava, trazia consigo, guardava, entregava e fornecia, ainda que gratuitamente, 13 porções de maconha, 45 pedras de crack e 25 pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela procedência da ação penal, com a cominação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A Defesa apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela absolvição do réu, por falta de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja a pena aplicada no mínimo legal, com a cominação do regime inicial aberto ou semi-aberto para o cumprimento da pena.

DECIDO.

Inicialmente, destaco que o princípio da identidade física do juiz comporta exceções, aplicando-se, por analogia, o disposto no artigo 132 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021, razão pela qual passo ao julgamento do feito.

No mérito, cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), pelo laudo toxicológico (fls. 126/128) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando, na fase judicial, que, no dia dos fatos, levou a sua esposa no ponto de ônibus e, em seguida, se dirigiu até o depósito para fazer um orçamento para sua genitora, sendo certo que, no trajeto, encontrou seu colega HYULLI.

O denunciado disse, ainda, que, durante o retorno para sua residência, decidiu passar em uma biqueira para comprar maconha, de modo que, ao chegar no campo de futebol, foi abordado pela Guarda Municipal.

O réu falou, também, que não estava com nenhuma mochila, esclarecendo que seu colega HYULLI desceu em um centro médico, que, ainda, encontrou um indivíduo conhecido como MARCOS, que faz serviços de internet, e que foi preso a uma distância de dez minutos do depósito, para onde tinha se dirigido inicialmente.

Contudo, suas alegações não encontram amparo na prova dos autos, eis que a prova oral colhida foi enfática em confirmar, sem sombras de dúvidas, o desenrolar fático apontado na denúncia, comprovando-se que, no mínimo, o réu transportava e guardava a mochila contendo drogas.

Neste sentido, a testemunha de acusação LUIZ CARLOS DE FREITAS, guarda municipal, na fase judicial, afirmou que teve conhecimento por populares que “havia entrado uma bicicleta com uma pessoa com a mochila nas costas”, em local conhecido como ponto de venda de drogas e onde várias pessoas já foram presas.

O guarda municipal disse, ainda, que visualizou “a bicicleta na subida do trilho”, de modo que efetuou o retorno no campo e avistou “o indivíduo no alto do morro”, ocasião em que, após ver a viatura, tentou deixar o local.

O agente público deixou claro que o guarda municipal RODRIGO ALVES subiu no trilho

e este indivíduo deixou a mochila e veio em direção à viatura, sendo certo que, após a abordagem, negou que estivesse trazendo consigo a mochila.

O guarda municipal esclareceu que, muito embora não tivesse visualizado mochila com o réu, “estávamos a uma distância de aproximadamente trinta ou quarenta metros quando avistamos na mata”, reafirmando que a mochila posteriormente apreendida continha drogas e dinheiro.

Na fase investigativa, o guarda municipal trouxe versão parecida, dizendo, contudo, que chegou a visualizar o réu em uma bicicleta com uma mochila nas costas (fls. 20).

No mesmo sentido, as declarações do guarda municipal RODRIGO ALVES, que, na fase judicial, afirmou que visualizou, após adentrar ao campo de futebol e subir na trilha, um indivíduo “soltando a mochila e ele fez o movimento de que ia se evadir.”

O guarda municipal disse que, após dar conta do ocorrido para o outro guarda e realizar buscas, localizou a mochila “que eu vi ele soltando ao solo”, sendo certo que, em seu interior, havia drogas, dinheiro e papel com anotações sobre o tráfico de drogas.

O agente público esclareceu que estava vinte metros do réu e que “durante a abordagem, ele me viu e voltou”, bem como que o guarda municipal LUIZ CARLOS DE FREITAS “não viu”.

Na fase policial, o guarda municipal trouxe versão idêntica sobre os fatos, em especial sobre o fato de o réu ter dispensado a mochila, logo após visualizar a viatura (fls. 22).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos guardas municipais, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os agentes públicos tivessem ingressado no mato, apreendido uma mochila contendo drogas e, após abordarem aleatoriamente o réu, sem anterior rixa ou desentendimento, forjaram um ato de flagrante, imputando-lhe a propriedade dos entorpecentes.

A reforçar esta linha de entendimento, não se pode olvidar que no interior da mochila havia grande quantidade de dinheiro (R\$ 1.306,50 – fls. 25/26), o que torna desarrazoado que estivesse abandonada no mato.

Não havendo, por conseguinte, nenhuma prova concreta que esteja a apontar, como pretende a Defesa, que a diligência foi forjada.

Muito pelo contrário, a testemunha de defesa HYULLI SILVA, que teria pegado uma carona com o réu para uma entrevista de emprego, na fase judicial, deixou claro que o último contato com o réu foi antes de sua prisão.

É certo que a testemunha chegou a dizer que apenas pegou uma carona até o final da alameda e que o réu não estava com uma mochila nas costas, sendo certo que, analisando o terceiro vídeo indicado às fls. 92, de fato, se extrai a presença de dois indivíduos em uma bicicleta, descendo a alameda, a tornar verossímil a versão

trazida pela testemunha HYULLI.

No entanto, esta versão não tem força suficiente para se constituir em álibi em favor do denunciado, na medida em que o vídeo em questão mostra a passagem da bicicleta às 08 horas e 06 minutos, uma hora antes da prisão do denunciado, ocorrida às 09 horas e 10 minutos (fls. 15), abrindo a possibilidade de o réu ter tido tempo suficiente para pegar a mochila e transportá-la, até ser abordado pela guarda municipal.

Analisando mais detidamente este vídeo, denota-se, inclusive, que havia duas pessoas que observavam a passagem do réu e da testemunha HYULLI durante a descida da ladeira, o que permite a conclusão de que possam ter sido os denunciantes, a coincidir com a versão dos dois guardas municipais e torná-la mais forte, quando comparada com a prova apresentada pela Defesa.

Neste ponto, cabe destacar que o próprio denunciado, na fase judicial, fez menção de que encontrou outras pessoas no trajeto, tal como o indivíduo conhecido como MARCOS, a afastar totalmente a possibilidade de que tinha a finalidade inicial apenas de se dirigir até a loja de material de construção, a pedido de sua genitora.

A este respeito, inclusive, deve-se salientar que não é possível utilizar as mensagens trazidas às fls. 102/103 em favor da Defesa, eis que foram trocadas, igualmente, antes da prisão do denunciado, sem desconsiderar que o réu, na fase judicial, disse, com todas as letras, que foi até a biqueira para comprar drogas, a enfraquecer ainda mais o álibi apresentado.

Neste panorama, com algumas pequenas e aceitáveis diferenças de percepção principalmente com referência ao guarda municipal LUIZ CARLOS DE FREITAS, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Fechando o conjunto probatório amplamente desfavorável à Defesa do denunciado PIERRY, não se pode desconsiderar o fato de não ter sido tecnicamente possível identificar impressões papilares no papel com anotações sobre o tráfico (fls. 224) ou, ainda, grafotécnicas do réu (fls. 280).

A rigor, a prova pericial verdadeiramente pouco seria favorável à Defesa, eis que, a partir da descrição da denúncia, não houve qualquer imputação no sentido de que o réu seria responsável pela contabilidade do entorpecente.

Em arremate, mister salientar que não há qualquer ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso dos autos, porquanto se tratou de situação de flagrante delito, que se revela cabível, diante do teor do artigo 301 do Código de Processo Penal.

A este respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto, em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 675.507/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).”

Em suma, todas as provas produzidas revelam a atividade material descrita no tipo penal, consistente, no mínimo, em guardar e transportar drogas para entregar a

consumo.

De tal sorte que a negativa do denunciado, desacompanhada de outras provas, acaba por ficar absolutamente isoladas diante do contexto probatório, o que se afigura mais do que suficiente para o enquadramento da conduta no verbo do tipo penal apontado na denúncia.

Portanto, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a considerar.

No mais, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, as peculiaridades do caso, especialmente o fato de as drogas serem de diversos tipos, quais sejam, cocaína, maconha e crack, a grande quantidade de dinheiro encontrado (R\$ 1.306,50 – fls. 25/26), o fato de o réu ter sido preso em local próximo no final do ano de 2020, segundo seu próprio interrogatório (Processo n.º 1502064-67/2020), cabendo destacar que a sua prisão também foi decretada naquele feito, pois descumpriu medida cautelar de não aproximação a este mesmo local, fazem concluir que se dedica a atividades criminosas.

Em acréscimo, cabe destacar que o papel com anotações encontrado no interior da mochila permite a conclusão de que o réu possui vínculo mais duradouro e forte com o tráfico de drogas, premissa que se sobrepõe à declaração de fls. 105 emitida pela empresa TEC MILLS.

Em arremate, cabe destacar que as circunstâncias de sua prisão, principalmente o fato de ter sido preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, tal como afirmaram os guardas municipais, está a indicar que tinha propensão a atividades criminosas.

A respeito da possibilidade de utilização das circunstâncias da prisão, principalmente quando relacionada com identificação de se tratar o local de ponto de venda de drogas, para este fim, confira-se o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO QUE CONTA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL EMPREGADO NA ORIGEM. CORRETA A REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE AUMENTO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Estatuto Repressivo, a natureza, a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

- No caso, a fundamentação utilizada para promover a exasperação da pena-base era idônea. De fato, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 184,2g de maconha e 85,8g de cocaína - desbordavam do ordinário do tipo e autorizavam algum quantum de incremento punitivo. Porém, não no patamar aplicado, na origem, que fugia à fração prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor desfavorecido, sem, contudo, explicitar qualquer razão especial que autorizasse o apenamento mais rígido, além do insito à circunstância judicial referida. Por isso, foi a ordem concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base do ora agravante para a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Na hipótese, a redutora do tráfico privilegiado não foi afastada somente em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, porquanto as instâncias de origem consignaram também que o ora agravante se dedicava ao tráfico de drogas, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia militar que ele estaria traficando drogas (o que foi confirmado por seus vizinhos) -, as quais realmente sugerem que não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, o apenado jus à aplicação da referida minorante. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

- O regime prisional permanece na modalidade fechada, considerando o quantum da reprimenda final (superior a 4 anos de reclusão e não superior a 8 anos de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

- Não há ilegalidade flagrante na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.  
(AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)."

A este respeito, indicamos o seguinte julgado da 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021.

Em suma, sob todos os ângulos analisados, possível concluir que não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)."

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Não se nega que, em função da cautelaridade da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em qualquer das vedações legais previstas na Lei n.º 12.403/11.

Contudo, no caso em exame, houve decreto de prisão preventiva, que esteve a considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em decisão até então mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

E, neste meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada.

Sendo assim, ainda mais agora que todo o contexto probatório está a indicar ter sido o réu autor do delito, nada há que esteja a justificar nova apreciação do pedido, sob pena de, por via transversa, desfazer-se situação jurídica consolidada e suprimir instância judicial.

Assim, sob todos os ângulos analisados, não há qualquer constrangimento ilegal que esteja sendo imposto à liberdade de locomoção do réu, sendo de rigor a manutenção da medida.

Ante o exposto, CONDENO PIERRY FERREIRA MACEDO, qualificado nos autos, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA